

背任罪に関する次の【判旨】についての後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。

【判 旨】

刑法第247条にいう「本人に財産上の損害を加えたとき」とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべきでありし価値が増加しなかったときをいうと解すべきであるところ、信用保証協会A支所長の被告人が同協会をして返済能力のないBの債務を保証させたときは、同債務がいまだ不履行の段階に至らず、したがって同協会の財産に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、経済的見地においては、同協会の財産的価値は減少したものと評価されるから、同条にいう「本人に財産上の損害を加えたとき」に当たるというべきである。

【記 述】

1. 【判旨】は、保証債務の負担を「財産上の損害」とし、背任罪を本人の全体財産に対する罪であることを否定している。
2. 【判旨】によれば、上記信用保証協会による上記保証債務の負担後、Bが偶然金銭を入手して主債務を期限内に弁済した場合に、背任罪の未遂罪の成立を認めることになる。
3. 【判旨】は、保証債務の負担が「財産上の損害」に当たるか否かを判断するに当たり、主債務者の返済能力を問わないとの判断をしたものである。
4. 【判旨】は、保証債務の負担をもって「財産上の損害」と認めているから、背任罪が侵害犯であることを否定している。
5. 【判旨】に対しては、どの程度の財産的価値の減少をもって「損害」というのが明確ではないという批判が可能である。

本問の【判旨】は、最決昭58.5.24（百選Ⅱ72事件）を題材としたものである。

1 誤っている

財産犯は、客体が、個別の財産又は財産上の利益である（個別財産に対する罪）か、あるいは個人の財産全体である（全体財産に対する罪）か、によって区別される。【判旨】は、保証債務の負担をもって「財産上の損害」としているが、その判断に当たっては、「『本人に財産上の損害を加えたとき』とは、経済的見地において本人の財産状態を評価し、被告人の行為によって、本人の財産の価値が減少したとき又は増加すべかりし価値が増加しなかったときをいう」としており、背任罪（247条）が、全体財産に対する罪であることを前提にしている。

2 誤っている

【判旨】は、「信用保証協会A支所長の被告人が同協会をして返済能力のないBの債務を保証させたときは、同債務がいまだ不履行の段階に至っておらず、したがって同協会の財産に、代位弁済による現実の損失がいまだ生じていないとしても、経済的見地においては、同協会の財産的価値は減少したものと評価されるから、同条にいう『本人に財産上の損害を加えたとき』に当たる」としている。このように【判旨】は、返済能力のない主債務に対する保証債務を負担させたことををもって「財産上の損害」が生じた（既遂となる）との考え方を示している。つまり、【判旨】は、代位弁済による現実の損失があった時点で既遂になるとは考えていない。よって、【判旨】によれば、本記述のようにBが主債務を弁済した場合、背任罪の未遂罪にとどまることにはならない。

3 誤っている

「財産上の損害」の判断方法として、財産の概念を法の見地から理解する法律的財産説と、経済的見地から理解する経済的財産説とがある。法律的財産説によると、権利の侵害があつてはじめて財産上の損害が認められる。これに対し、経済的財産説によると、権利侵害の有無にかかわらず、財産は経済的に評価される。【判旨】は、「被告人が同協会をして返済能力のないBの債務を保証させたときは、……経済的見地においては、同協会の財産的価値は減少したものと評価される」として、経済的財産説の立場から「財産上の損害」を認めている。よって、【判旨】は、保証債務の負担が「財産上の損害」に当たるか否かを判断するに当たり、主債務者の返済能力を問わないとの判断をしたとはいえない。

4 誤っている

背任罪には未遂犯処罰規定がある（250条）ことから侵害犯である。つまり、本罪の他の要件を充たすが「財産上の損害」が生じなかった場合は未遂犯となるが、「財産上の損害」が生じていれば既遂犯となる。【判旨】は、経済的見地からみて、返済能力のない主債務に対する保証債務を負担したときは、「財産上の損害」に当たるとの判断を示している。よって、【判旨】は、単なる保証債務の負担をもって「財産上の損害」と認めたわけではなく、また、背任罪が侵害犯であることを否定したわけでもない。

5 正しい

【判旨】は、「財産上の損害」の判断基準として経済的財産説に立つが、同説については、「財産上の損害」の評価について経済的見地から行うとしても、どの段階で実際に「財産中の損害」という結果が生じるのかは、なお不明な側面があるといわれている。よって、【判旨】に対しては、どの程度の財産的価値の減少をもって「損害」というのが明確ではないとの批判が可能である。したがって、本記述は正しい。